

1529803-17.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529803-17.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529803-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336857/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 21889450 - 101º

D.P. JDIM IMBUÍAS, 2336857 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN ASSUNÇÃO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO e CHRISTIAN ASSUNÇÃO DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta de 03h30min, na Rua Sabino Romariz, nº 563, bairro Grajaú, nesta cidade e comarca da Capital, os acusados, agindo em concurso com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 43 porções de cocaína, com peso

líquido de 16,2g; 02 porções de LSD, com peso líquido de 0,02g; 21 porções de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com o peso líquido de 70,6g; e 28 porções de crack, com o peso líquido de 7,8g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, os denunciados decidiram praticar o tráfico ilícito de drogas, tanto que traziam consigo as substâncias entorpecentes apreendidas. Nessas circunstâncias, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, já conhecido pelo tráfico de drogas, quando se depararam com CHRISTIAN dormindo em uma viela, fato que despertou suspeita, deliberando pela abordagem.

Em revista pessoal, nada foi localizado em poder de CHRISTIAN, porém, questionado, ele confessou informalmente ser olheiro do tráfico. Na sequência, os policiais militares continuaram entrando na viela quando se depararam com JOÃO MARCOS, a poucos metros de distância, também dormindo. Resolveram abordá-lo e, em revista pessoal, localizaram as diversas porções de drogas sob suas vestes, em uma sacola plástica, bem como a quantia de R\$ 272,05 em espécie.

Formalmente interrogado, CHRISTIAN confessou estar vendendo as drogas e que JOÃO MARCOS estava apenas comprando entorpecentes, não traficando. Por sua vez, JOÃO MARCOS negou o tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia de fls. 01/04, foi ela recebida (fls. 138/141). Os acusados foram notificados (fls. 128/130), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 134/135). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de junho de 2022 (fls. 189/141).

No dia de hoje, realizada a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e os réus, ao final, foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em debates.

O Ministério Público requereu a condenação de ambos. Em relação a Christian, concordou com a concessão do privilégio, regime aberto e recurso em liberdade. Quanto a João Marcos, reincidente específico, requereu a condenação sem o redutor, regime fechado.

A defesa, em relação a ambos, pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, em relação ao Christian, a aplicação do redutor em grau máximo, regime aberto e recurso em liberdade. Em relação a João Marcos, pena mínima e regime diverso do fechado com recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 08/10); o auto de prisão em flagrante (fls. 05/11); o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação provisória, fls. 20/23, folhas de antecedentes dos acusados (fls. 42/44; 45/48; 102/105; 109/110) e laudo químico toxicológico, fls. 164/166.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e dos laudos de constatação provisória (fls. 20/23), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 164/166), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Policia! Brendam declarou que no dia dos fatos, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionado por um paisano que delatou o trafico em uma viela. Foram ao local e lá se depararam com um rapaz sentado em uma cadeira, com um celular ligado na tomada. Esse que estava na cadeira reconhece com Cristiano que admitiu ser olheiro. O parceiro andou mais um 10 metros e encontrou João marcos, o que tem uma

tatuagem no rosto, dormindo segurando uma bolsa. Dentro da bolsa encontrou maconha, dinheiro, crack ou cocaína. Se não se engana "loló" e dinheiro. Os fatos ocorreram na madrugada.

Já o policial Gabriel reconheceu os acusados de uma ocorrência de tráfico. Estava em patrulhamento quando avistaram os indivíduos em uma viela. Um estava deitado no chão e o outro estava atrás de uma porta de metal, também deitado. Entrou na viela para averiguar e primeiro o parceiro conversou com Christian e a testemunha foi conversar com o que estava atrás da porta. Perguntou para o que estava deitado onde estava a droga e ele disse que estava na calça debaixo dele. Revistaram os dois. João Marcos estava com duas calças e o saco com drogas estavam entre as calças. Pinos de cocaína, crack, dois potes de LSD, dinheiro foram localizados. Christian admitiu ser olheiro e João Marcos permaneceu em silêncio. Não se recorda a quantidade de dinheiro.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão dos acusados, obtida em juízo, vejamos.

Christian tem 20 anos de idade. Mora com a mãe, a avó e com o irmão. Na época da prisão estava trabalhando mas o movimento estava fraco. Tem uma filha de 3 anos que mora com a mãe. Nunca foi processado anteriormente. Reconhece que estava ali como "olheiro", ou seja, teria que avisar quando e se alguma viatura passasse. Era a primeira vez. Ia ganhar 50 reais. Não estava com João e não chegou a vê-lo. Somente o viu quando os policiais o trouxeram. Se passasse algum comprador, passaria pelo interrogando e seguiria até onde se encontravam os traficantes. Gostaria de uma chance.

João Marcos declarou que tem 23 anos de idade. Mora com a tia. Não tem filhos. Trabalhava fazendo bico em uma adega, como entregador. Reconhece que estava vendendo entorpecente. Reconhece que estava na posse do dinheiro e do entorpecente apreendido e que este seria destinado a venda a terceiros. Também admitiu e que o dinheiro era decorrente do tráfico.

Como se percebe, a prova impõe o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena:

1) JOÃO MARCOS

Fixo a pena base no mínimo. Observo, por relevante, que entendo não ser o caso de aumentar a pena base em razão da quantidade de entorpecente apreendida na medida em que o caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Daí porque entendo que a quantidade de droga apreendida não justifica o aumento nesta primeira fase.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, verifico que o réu é reincidente mas confessou o crime. Daí porque, em discordância do que foi postulado pelo Ministério Público, compenso integralmente a agravante com a atenuante porque, embora reincidente específico, entendo que a compensação integral é medida mais adequada no caso concreto.

Reincidente específico, fls. 50/51, não pode ser beneficiado com o privilégio previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim sua pena definitiva é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O valor do dia multa em função de sua evidente hipossuficiência é o mínimo.

O regime de início de cumprimento de pena é o fechado pois, reincidente específico, não faz jus a regime menos menos gravoso.

Ademais, está condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado aos hediondos, que não admite tratamento mais benéfico.

2) CHRISTIAN

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal.

Em segunda fase, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, nos termos das ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 49. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, em relação a Christian, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e o faço para CONDENAR:

1) CHRISTIAN ASSUNÇÃO DE JESUS, RG: 52300158 demais qualificações nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato. Recurso em liberdade, expeça-se em relação a ele alvará de soltura clausulado.

2) JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO, RG: 58888747, demais qualificações nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado e 500 (quinhentos) dias multa, piso mínimo e corrigidos desde a data do fato. Sem recurso em liberdade.

Em relação a Christian, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Em relação a João Marcos, Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do

réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva do réu porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 15). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 5) Transitada esta em julgado tornem conclusos para, em relação a Christian, seja designada data para audiência admonitória. 5) Em relação a João Marcos, extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA